

<제3편 제1심의 소송절차.제5장 소송 개시와 심리 대상.제8절 채권자대위소송에 대한 주요 논점>

I. 의의

- 채권자대위소송이란 채권자가 자신의 채권을 보전하기 위하여 채무자의 제3채무자에 대한 권리를 채무자를 대신하여 행사하는 소송이다. 이는 실체법상 채권자대위권(민법 제404조)에 근거를 두고 있으나, 소송법적으로는 당사자적격의 소재와 기판력의 확장 범위 등 독특한 쟁점을 다수 포함하고 있다.

II. 채권자대위소송의 법적 성질 ★

1. 법적 성질

- 채권자대위소송의 법적 성질에 관하여는 채권자가 자신의 권리를 행사하는 것이라는 견해와 채무자의 대리인으로서 소송을 수행하는 것이라는 견해가 대립한다. 통설과 판례는 채권자가 법률의 규정에 의하여 타인의 권리에 대하여 소송수행권을 부여받는 법정소송담당으로 파악한다. 그중에서도 채무자의 의사와 관계없이 제기할 수 있다는 점에서 갈음형 법정소송담당에 해당한다.

2. 대위소송의 요건흡결 시 처리

- 채권자대위소송의 요건(채권보전의 필요성, 채무자의 권리불행사 등) 중 일부는 실체법상 권리 발생 요건인 동시에 소송법상 당사자적격을 결정하는 요소가 된다. 따라서 피보전채권이 존재하지 않거나 채무자가 이미 스스로 권리를 행사하고 있는 경우, 법원은 본안 심리를 하지 않고 원고의 당사자적격 흡결을 이유로 소각하판결을 내려야 한다.

III. 채권자대위소송과 중복소제기

1. 채권자대위소송 계속 중 채무자가 소를 제기한 경우

- 채권자가 먼저 대위소송을 제기하여 소송계속이 발생한 후, 채무자가 동일한 피대위권리를 대상으로 제3채무자에게 소를 제기하는 경우이다. 판례는 채권자대위소송의 소송물과 채무자의 직접 소송의 소송물은 동일하다고 보므로, 채무자가 나중에 제기한 소는 중복소제기에 해당하여 부적법하다.

2. 채무자의 제3자에 대한 소송 중 채권자대위소송이 제기된 경우

- 채무자가 이미 제3채무자를 상대로 소를 제기하여 재판이 진행 중이라면, 채권자대위소송의 요건인 채무자의 권리불행사를 충족하지 못하게 된다. 이 경우 나중에 제기된 채권자대위소송은 당사자적격이 없는 자에 의한 소로서 소송요건 흡결로 각하된다.

3. 채권자대위소송 계속 중 다른 채권자가 다시 대위소송을 제기한 경우

- 수인의 채권자가 동일한 피대위권리에 대하여 각자 대위소송을 제기하는 경우이다. 먼저 제기된 소송이 계속 중이라면 나중에 제기된 다른 채권자의 대위소송은 소송물이 동일하므로 중복소제기에 해당한다.

4. 압류채권자의 추심소송 중 채무자가 별소를 제기한 경우

- 추심명령을 받은 채권자가 제기하는 추심소송도 법정소송담당의 일종이다. 추심소송이 계속 중일 때 채무자가 동일한 채권에 대해 소를 제기하는 것은 중복소제기 금지 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.

5. 채무자가 제소한 후 압류채권자가 추심소송을 제기한 경우

- 채무자가 먼저 소를 제기한 경우 압류채권자는 별소를 제기할 수 없다. 대신 압류채권자는 채무자의 소송에 승계참가하거나 공동소송인으로 참가하여 자신의 권리를 보호받아야 한다.

IV. 피대위자의 재소금지 여부

1. 문제점

- 채권자가 대위소송을 제기했다가 판결 선고 후 소를 취하한 경우, 채무자가 나중에 직접 소를 제기하는 것이 재소금지 원칙(민소법 제266조 제2항)에 저촉되는지가 문제된다.

2. 학설

- 채권자와 채무자는 별개의 인격체이므로 재소금지가 적용되지 않는다는 견해와, 소송물이 동일하므로 채무자도 재소금지의 효력을 받는다는 견해가 대립한다.

3. 판례

- 판례는 채무자가 채권자대위소송이 제기된 사실을 알았을 때에 한하여, 채권자의 소취하에 따른 재소금지의 효력이 채무자에게도 미친다고 판단한다. 이는 기판력의 확장 원리를 재소금지에도 유추 적용한 결과이다.

4. 검토

- 채무자가 소송 제기 사실을 알았다면 스스로 권리를 행사할 기회가 있었음에도 방치한 것이므로, 절차적 안정을 위해 재소금지의 효력을 인정하는 판례의 태도가 타당하다.

V. 채권자대위소송과 기판력의 확장

1. 채권자대위소송 확정판결의 효력이 채무자에게 미치는지 여부

- 과거에는 채무자가 소송에 참가하거나 고지받은 경우에만 미친다는 견해가 있었으나, 현재 판례는 채무자가 대위소송이 제기된 사실을 어떤 경로로든 알았을 경우에는 그 확정판결의 효력이 채무자에게도 미친다고 본다.

2. 채무자의 제3채무자에 대한 확정판결의 효력이 대위채권자에게 미치는지 여부

- 채무자가 제3채무자를 상대로 제기한 소송에서 패소 판결이 확정되었다면, 그 기판력은 법정소송담당의 원리에 따라 채권자에게도 미친다. 따라서 채권자는 동일한 권리에 대해 다시 대위소송을 제기할 수 없다.

3. 채권자대위소송 확정판결의 효력이 다른 채권자에게 미치는지 여부

- 수인의 채권자들 사이에서도 소송물이 동일하므로, 어느 한 채권자가 얻은 확정판결의 효력은 다른 채권자에게도 미친다. 다만, 이는 채무자가 소송 계속 사실을 알았을 것을 전제로 한다.

4. 채권자의 채무자를 상대로 한 소송의 확정판결의 효력이 제3채무자를 상대로 한 채권자대위소송에 미치는지 여부

- 채권자가 채무자를 상대로 피보전채권의 존재를 확인받거나 이행 판결을 받은 경우, 그 기판력은 대위소송에서의 피보전채권 존부 판단에 영향을 미친다. 제3채무자는 대위소송에서 채무자가 주장할 수 없는 사유로 채권자의 피보전채권을 다툴 수 없다.

5. 채권자의 제3채무자를 상대로 한 채권자대위소송 확정판결의 효력이 채권자의 채무자를 상대로 한 소송에 미치는지 여부

- 대위소송에서 제3채무자가 승소(청구기각)하더라도 이는 피대위권리의 부존재를 확정할 뿐이다. 따라서 채권자가 채무자를 상대로 제기하는 피보전채권 자체에 관한 소송에는 기판력이 미치지 않는다.

V. 원시적 공동소송의 가부

1. 대위채권자와 채무자의 공동소송

- 채권자가 대위소송을 제기하면서 채무자를 공동피고로 삼아 피보전채권의 이행을 구하는 소송(이른바 대위소송과 본안소송의 병합)은 실무상 널리 허용된다.

2. 수인의 대위채권자의 공동소송

- 여러 채권자가 처음부터 공동하여 대위소송을 제기하는 경우, 이는 민사소송법 제65조 전단에 의한 공동소송으로서 통상공동소송이 된다.

VI. 공동소송참가와 보조참가의 가부

1. 채권자대위소송 계속 중 채무자가 참가하는 경우

- 채무자는 소송 결과에 따라 자신의 권리가 확정되므로 이익관계가 명백하다. 채무자는 채권자의 소송에 공동소송참가(민소법 제72조)를 하여 직접 당사자로서 권리를 주장할 수 있다.

2. 채무자의 제3자에 대한 소송 중 채권자가 참가하는 경우

- 채권자는 채무자가 승소해야 자신의 채권을 보전할 수 있으므로 법률상 이해관계가 있다. 따라서 채권자는 채무자의 승소를 돕기 위해 보조참가를 할 수 있다.

3. 채권자대위소송 계속 중 다른 채권자가 참가하는 경우

- 다른 채권자는 먼저 소를 제기한 채권자와 소송목적이 결정적으로 동일하므로 공동소송참가를 할 수 있다. 만약, 별소를 제기하면 중복소제기가 되므로 참가가 강제되는 측면이 있다.

VII. 결론

- 채권자대위소송은 다수의 이해관계인이 얹힌 복합적인 소송 형태로서, 소송물 및 기판력의 법리가 당사자 확정의 핵심을 이룬다. 판례가 채무자가 알았는지 여부를 기준으로 기판력과 재소금지의 범위를 확정하는 것은 채무자의 절차적 기본권을 보호하면서도 판결의 모순을 방지하려는 합리적 선택이다. 중복소제기 논의 역시 채무자의 권리 행사가 우선한다는 원칙 하에 대위채권자의 지위를 보충적으로 파악함으로써 절차적 혼란을 최소화하고 있다. 법원은 대위소송의 특수성을 고려하여 당사자적격의 존부를 엄격히 심사하되, 공동소송참가 등의 제도를 적극 활용하여 관련 분쟁이 하나의 절차 내에서 모순 없이 해결될 수 있도록 유도하여야 할 것이다.